

<제9장 무효등 확인소송.제1절 무효등 확인소송의 의의>

I. 개념[행소법 제4조 제2호]

- 무효등 확인소송이란 행정청의 처분등(재결 포함)의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 소송을 말한다. 행정소송법 제4조 제2호는 항고소송의 한 종류로서 무효등 확인소송을 명시한다. 여기서 무효등은 해당 처분등에 중대하고 명백한 하자가 있어 처음부터 법적 효력이 발생하지 않았음을 확인하는 무효 확인을 핵심으로 하면서, 처분의 유효 확인, 부존재 확인, 실효 확인 등 처분등의 효력 또는 존재와 관련된 모든 확인 소송을 포괄하는 개념이다. 이 소송은 법적으로 불명확한 상태에 놓여 있는 처분등의 법적 상태를 재판을 통해 명확히 함으로써, 그 처분을 둘러싼 법률관계의 불안정성을 제거하고 국민의 권리 또는 법률상의 이익을 보호하는 것을 목적으로 한다. 처분의 효력 자체를 다투는 점에서 위법한 처분의 취소를 구하는 취소소송과는 구별되는 독자적인 소송 유형이다.

II. 종류

- 무효등 확인소송은 확인을 구하는 대상 및 내용에 따라 그 종류를 구별할 수 있다.

1. 무효확인소송

(1) 의의와 성격

- 무효확인소송은 행정처분등에 중대하고 명백한 하자가 존재하여 처음부터 법적 효력(공정력)이 발생하지 않았음을 확인하는 소송이다. 이는 행정행위의 하자가 취소 사유에 그치는 경우(위법하지만 일단 유효)와 달리, 행정행위가 아예 권한을 넘어서거나 절차상 본질적인 하자를 포함하여 법적 존재 자체가 부정되는 경우에 제기된다. 무효인 처분은 법적으로 누구에게나 효력이 없으나, 재판을 통해 그 무효임을 공적으로 확인받아 공적인 증명력을 부여하고 법률관계의 불확실성을 완전히 해소하기 위해 제기된다.

(2) 취소소송과의 관계

- 무효확인소송과 취소소송은 모두 행정행위의 위법성을 다투는 항고소송이라는 점에서 공통점을 가진다. 그러나 양자는 처분의 하자의 정도와 소송 요건에서 중대한 차이가 있다. 취소소송은 제소기간의 제한을 받고(안 날로부터 90일, 있은 날로부터 1년), 행정심판 전치주의가 적용될 수 있으나, 무효확인소송은 그 처분의 효력이 처음부터 없으므로 제소기간의 제한을 받지 않으며, 행정심판 전치주의도 적용되지 않는다. 판례는 이 두 소송을 병렬 관계로 보아, 원고가 소송 요건을 충족하는 한 목적을 가장 효과적으로 달성할 수 있는 항고소송의 종류를 선택할 수 있다고 본다.

2. 유효·부존재·실효확인소송

(1) 유효확인소송

- 유효확인소송은 이미 발생한 행정처분등의 효력이 유효함을 확인하는 소송이다. 이는 처분의 효력에 대하여 다툼이 있어 무효의 위험이 존재하는 경우, 그 법적 불확실성을 제거하고 처분의 공정력과 집행력을 확고히 하기 위해 제기되며, 주로 처분의 효력을 주장하는 이해관계인이나 행정청 자신이 제기한다.

(2) 부존재확인소송

- 부존재확인소송은 행정청의 행위가 외형상 존재하는 것처럼 보일지라도, 행정행위로서의 성립 요건을 갖추지 못하여 아예 행정처분 자체가 성립되지 않았음을 확인하는 소송이다. 이는 처분등에 대한 오인으로 인한 법률관계의 불안을 해소한다.

(3) 실효확인소송

- 실효확인소송은 이미 유효하게 성립한 처분등의 효력이 특정한 사유(법령의 폐지, 부관의 성취, 적법한 철회 등)로 인해 장래를 향하여 소멸하였음을 확인하는 소송이다. 이는 처분의 효력이 소멸한 시점 이후의 법률관계의 안정성을 확보하는 데 그 필요성이 있다.

III. 필요성

- 무효등 확인소송은 행정소송의 기능, 특히 국민의 권리 구제 측면에서 다음과 같은 필수적인 기능을 수행한다.

1. 권리 구제의 실효성 확보

- 무효등 확인소송, 특히 무효확인소송은 취소소송의 제소기간 제한을 극복하여 국민의 권리 구제를 실질적으로 보장한다. 처분의 무효는 시간의 경과로도 치유되지 않으므로, 제소기간이 도과된 후에도 언제든지 무효확인소송을 제기할 수 있어 국민의 쟁송 기회를 항구적으로 보장한다. 이는 행정의 위법성 통제를 영구적으로 유지하여 행정의 적법성을 확보하게 한다.

2. 공정력 통제의 최종 수단

- 행정행위의 하자는 정도에 따라 무효 사유(중대하고 명백한 하자)와 취소 사유(중대하고 명백하지 않은 하자)로 나뉜다. 무효확인소송은 공정력이 미치지 않는 당연 무효인 처분을 대상으로 하여, 법적 불안정을 해소하는 사법 통제의 최종적인 수단이 된다. 비록 무효인 처분은 법적으로 효력이 없으나, 이해관계가 얽힌 복잡한 법률관계에서 법원의 공적 확인을 받지 못하면 제3자나 후행 행정청과의 분쟁이 계속될 수 있으므로, 소송을 통한 확인은 법적 안정성을 위해 필수적이다.

3. 확인의 소의 보충성 배제

- 민사소송법상 일반적인 확인의 소는 다른 직접적인 구제 수단(이행 소송)이 없는 경우에만 인정되는 보충성이 요구된다. 그러나 행정소송법 제35조에 처분등의 효력 유무 또는 존재 여부의 확인을 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다고 규정하고 있으며, 이와 별도로 보충성이 요구되지 않는다는 것이 판례의 확립된 태도이다. 이는 무효확인판결 자체에 취소판결의 기속력에 관한 규정이 준용됨으로써 판결의 실효성이 확보되고, 무효확인소송이 취소소송을 보충하는 기능을 수행할 수 있기 때문이다. 따라서 이행 소송 등 직접적인 구제 수단이 존재하는 경우에도 무효확인소송을 제기할 수 있어 국민의 구제 경로를 넓힌다.

IV. 결론

- 무효등 확인소송은 행정처분등의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 항고소송의 한 종류이다. 이 소송은 중대하고 명백한 하자가 있는 처분을 대상으로 하여 취소소송의 제소기간 제한을 극복하고, 법률관계의 불안정성을 공적으로 해소함으로써 국민의 쟁송 기회와 권리 구제의 실효성을 최대한으로 보장하는 데 그 핵심적 필요성이 있다. 특히 판례가 확인 소송의 보충성을 요구하지 않는 태도를 취함으로써, 무효등 확인소송은 행정의 위법성을 통제하고 국민의 권익을 보호하는 데 있어 중요한 최종적인 사법적 수단으로 확고히 기능한다.